

1500817-72.2021.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público denunciou MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS e ROBERT TEREZA, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Drogas, sob alegação de que "...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500817-72.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500817-72.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

O Ministério Público denunciou MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS e ROBERT TEREZA, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Drogas, sob alegação de que "... na noite de 10 de maio de 2021, por volta de 18hs, na Travessa Amizade, n 23, Estufa, nesta cidade e comarca de Ubatuba, Marcelo Rodrigues dos Santos, qualificado a fls.08, e Robert Tereza, qualificado a fl. 09, traziam consigo, para fins de tráfico, 226 microtubos de cocaína (220,76g), 95 pedras de "crack" (46,96g) e 93 porções de maconha (171,69g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado)..." (fl. 110).

Em análise do flagrante, houve conversão em preventiva (fls. 78/82).

Após defesas prévias de fls. 113 e 120/121, a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021 (fls. 155/156).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas acusatórias, interrogados os réus ao final.

Memoriais do Ministério Público pela procedência (fls. 220/224).

Memoriais da Defesa de Marcelo pela absolvição (fls. 228/231). Memoriais da Defesa de Robert pela aplicação de atenuantes, regime mais brando de pena e direito de recorrer em liberdade (fls. 232/238)

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Preliminarmente, destaco que o Magistrado que presidiu a instrução foi promovido para a entrância final, de modo que afastada a sua vinculação para o julgamento do feito.

Em recentíssimo julgado, o C. Superior Tribunal de Justiça reafirmou que “[...] A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)”.

Não é outro o entendimento do E. TJSP:

“Nulidades – Princípio processual penal da identidade física do juiz – Exceções – Entendimento do art. 132 do CPC O princípio processual da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, é de suma importância, uma vez que o Juiz destinatário da prova, ao acompanhar a colheita dos elementos probatórios, estará por certo mais apto para formar o correto convencimento a respeito dos fatos. Existem, todavia, situações específicas nas quais caberá, excepcionalmente, a prolação de sentença por Magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, de modo a não se justificar, apenas com lastro nesse argumento, o descarte de todo o arcabouço probatório existente nos autos. A identidade física do juiz comporta, com efeito, exceções, devendo ser aplicada analogicamente, ante a omissão do texto do CPP, a previsão contida no art. 132 do CPC, consoante a qual cessa a vinculação do Juiz, titular ou substituto, que concluiu a audiência, na hipótese de ter sido ele convocado, estar licenciado ou afastado por qualquer motivo, ter sido promovido ou ter se aposentado; em todas essas situações a prolação de sentença passa a ser incumbência do respectivo sucessor. O fato de o CPC vigente não mais prever as referidas exceções não afasta sua aplicabilidade em atenção ao princípio da celeridade processual. O Projeto de Lei do Novo Código de Processo Penal contém dispositivo com redação no mesmo sentido. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0059187-27.2016.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)” Destaquei.

Passado tal ponto, e presentes os pressupostos processuais, passo ao mérito. O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos documentos produzidos em sede policial, notadamente auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 152/154), bem como pelas demais provas orais

produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Da prova oral produzida sob contraditório, extraem-se os seguintes depoimentos:

Testemunha Policial Diego disse que: a equipe estava em patrulhamento preventivo; ao adentrar na rua botafogo, foi possível visualizar 2 indivíduos na esquina; ao perceberem a presença da equipe, se evadiram; um deles segurava uma sacola plástica na mão e outro correu segurando algo na cintura; eles entraram em uma obra abandonada; a equipe foi até o local, vistoriou o local e no último cômodo encontrou os dois indivíduos agachados; Marcelo estava agachado no canto segurando a sacola na mão, que a soltou quando foi clareado com a lanterna; em busca pessoal, no bolso de sua bermuda, havia dinheiro; na sacola, estavam os entorpecentes; ao lado de Marcelo, estava roberto; em busca pessoal, nada de ilícito com ele; porém, no local em que agachado, havia um simulacro de pistola; informalmente eles confirmaram o tráfico; na ocasião, o réu Robert disse que sua função era de olheiro em apoio a Marcelo.

Testemunha Policial Henrique narrou que: visualizaram 2 indivíduos no final da via; eles correram quando vira a viatura; um segurando uma sacola e outro segurando algo na cintura; foram em direção a uma obra; encontraram os dois abaixados dentro da obra; com Marcelo, estava na sacola; no mesmo cômodo estava roberto; em busca pessoal deste, nada encontrado, porém, em um canto, havia um simulacro de arma de fogo; Marcelo admitiu que estava traficando; Roberto disse que ficava apenas ali, mas não tinha participação na venda, atuando como olheiro.

Em interrogatório, o réu Marcelo negou os fatos. Disse que não estava com a sacola que continha drogas. Estava voltando do mercadinho, foi comprar uma bolacha para seu filho. Os policiais o revistaram, não encontraram nada e o levaram para a delegacia. Os policiais levaram até a delegacia informando que iriam averiguar. Quando chegou à delegacia soube que estava sendo preso. Somente conhece Roberto de vista.

Em interrogatório, o réu Roberto admitiu o tráfico. Disse que estava passando necessidade. A droga era sua, recebeu para venda em decorrência da necessidade. A sacola era sua. Não reconhece o simulacro. Somente viu na delegacia. Somente viu o réu Marcelo na delegacia. A droga era sua, Marcelo não tem envolvimento.

As versões trazidas pelos réus são completamente diferentes dos relatos das testemunhas policiais.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

No caso concreto, diferentemente do que aponta a defesa, a instrução revelou que os policiais efetivamente visualizaram os réus correndo, MARCELO com a sacola posteriormente apreendida com entorpecentes e ROBERT auxiliando a atividade do tráfico, do contrário sequer teria tentado se evadir da abordagem policial.

O réu MARCELO sequer arrolou qualquer familiar como testemunha a fim de corroborar sua versão de que teria a um supermercado comprar alimento, versão completamente dissociada dos demais elementos constantes dos autos.

Portanto, a responsabilização dos réus é de rigor.

Passo, portanto, à dosagem das penas.

RÉU MARCELO

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, principalmente porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que processos em curso não podem ser valorados em tal circunstância; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de entorpecentes não se mostra relevante ao ponto de majorar a pena base. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena inicial em 05 anos reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes. Ausentes agravantes. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar.

Não há causas de aumento. Observa-se ser aplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, considerando os elementos constantes dos autos, estão preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de participação em organização criminosa e de ligação com atividades delituosas). A redução deverá ser patamar máximo, considerando que não houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes e inexistem elementos para afastar a redução no maior patamar.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a, de forma definitiva, em 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto, destacando que o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu, em regime de repercussão geral, que “é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (Tema 972). Ademais, a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o tráfico privilegiado não é delito hediondo ou equiparado, o que veio a ser expressamente mencionado pela Lei 13.964/2019.

As circunstâncias judiciais indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, valendo salientar que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já definiu que “é inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006” (Tema 626).

RÉU ROBERT

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu possui maus antecedentes (processo 7000238-24.2007.8.26.0625 – fl. 62), nos termos do Tema de Repercussão Geral 150 (“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”); não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu, principalmente porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que processos em curso não podem ser valorados em tal circunstância; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de entorpecentes não se mostra relevante ao ponto de majorar a pena base. Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena inicial em 05 anos e 10 meses reclusão e 583 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Presente, também, a agravante

da multirreincidência (processos 7002015.10.2008.8.26.0625 e 7002016-92.2008.8.26.0625 e 7002415-53.2010.8.26.0625 – fls. 62/64). Compenso a confissão com uma das reincidência e, em relação as duas remanescentes, aumento a pena em 1/5, fixando-a em 7 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Inaplicável o tráfico privilegiado ao referido réu, ante a sua múltipla reincidência, tornando definitiva a pena em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Ante a reincidência, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, considerando que o tempo de prisão provisória não é suficiente para fixação de regime mais brando.

Diante da quantidade da sanção, inviável a substituição por restritiva de direitos ou concessão da suspensão condicional da penal, benefícios que também não são compatíveis com a múltipla reincidência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, o que faço para:

(a) CONDENAR o réu MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado;

(b) CONDENAR o réu ROBERT TEREZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Substituo a pena privativa de liberdade do réu MARCELO por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, esta no valor de 01 salário mínimo a ser destinada a entidade conveniada ao Juízo da Execução, e prestação de serviços à comunidade, esta conforme as regras que serão estabelecidas pelo Juízo da Execução. Concedo ao réu MARCELO o direito de recorrer em liberdade, uma vez que incompatível a permanência da prisão cautelar com o regime de quantidade de pena. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Em relação ao réu ROBERT, permanece a necessidade de continuidade da custódia cautelar, considerando sua múltipla reincidência, indicativo de risco concreto de reiteração delitiva. Recomende-o na prisão em que se encontra.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Concedo a justiça gratuita aos réus.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, certidão para recebimento de honorários aos advogados, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, e, oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (art. 72, §6, NSCGJ).

Ubatuba, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA